

1502047-55.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Juliana Nobrega Feitosa

Comarca: Franco da Rocha

Foro: Foro de Franco da Rocha

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/01/2022

... a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas é medida de rigor.

Passo à aplicação da pena.

A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando ligada tanto às particularidades fáticas do caso concreto quanto às especificidades subjetivas dos agentes. No crime de tráfico de drogas, a expressa dicção legal do artigo 42 da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franco da Rocha

Foro de Franco da Rocha

Vara Criminal

Praça Ministro Nelson Hungria n °01, Franco da Rocha-SP - cep 07850-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502047-55.2021.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502047-55.2021.8.26.0544 - Controle n.º 1628/2021

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2232267/2021 - DEL.POL.FRANCO

ROCHA, 19858727 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2673/21/204 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2232267

- DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO THOMAZ FERREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Juliana Nobrega Feitosa

Vistos.

DIEGO THOMAZ FERREIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções cominadas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 25 de agosto de 2021, por volta das 14h40, na Rua Hipólito Trigoli Santiago, 588, Jardim Cruzeiro, nesta cidade e comarca, estaria trazendo consigo, com a suposta finalidade de entrega a consumo de terceiras pessoas, 28,81g de tetrahydrocannabinol, droga popularmente conhecida como "maconha", acondicionada em

47 porções, o que estaria fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da apreensão da quantia de R\$ 104,00 (cento e quatro reais) em dinheiro, nos termos da denúncia de fls. 81/82.

A denúncia foi recebida em 15 de setembro de 2021 (fl. 83). O réu foi citado (fls. 103/104), tendo sido apresentada resposta à acusação (fls. 126/127). Ante a ausência de hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (fl. 128), realizou-se a instrução criminal (fl. 130), na qual foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum e, após, o réu foi interrogado. Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a procedência do pedido condenatório, nos exatos termos da denúncia, com a aplicação da atenuante da confissão. Por sua vez, a Defensoria Pública pleiteou, resumidamente, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a agravante da reincidência, assim como o afastamento da agravante referente ao estado de calamidade.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, verifico a inexistência de quaisquer nulidades, bem como não ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal, pelo que passo à apreciação do mérito.

A materialidade delitiva se encontra consubstanciada no boletim de ocorrência de fls. 02/03, no auto de exibição e apreensão de fl. 07, no laudo de constatação provisória de fls. 14/16, no laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 72/74, bem como na prova oral coligida.

A autoria encontra-se cabalmente demonstrada, já que o cotejo probatório aponta o acusado como autor da prática criminosa, conforme depoimento das testemunhas, aliado à sua confissão.

Em solo policial (fl. 06), o acusado confessou a prática do crime, informando que "(...) estava traficando drogas no momento em que foi abordado e preso pela Polícia Militar portando porções de maconha e R\$ 104,00 (cento e quatro reais) em dinheiro. Não foi agredido na ação. Declara, por fim, que em média ganha R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por dia com a venda de entorpecentes".

Interrogado em juízo, o acusado assumiu a autoria delitiva, apresentando a versão de que vendia drogas fazia um mês e que, no momento, vendia maconha.

A versão apresentada pelo acusado pode ser acolhida por este juízo como sendo a realidade dos fatos, porquanto foi confirmada pelos demais elementos de prova dos autos, os quais não deixam dúvidas de que o acusado cometeu o crime de tráfico de drogas, apreendidas.

Com efeito, o policial militar Ailton Pereira da Silva, ouvido em delegacia à fl. 04, disse que, na data dos fatos, "efetuava patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas local, quando já no fim da rua, saindo de um tapume rastejando em um muro improvisado, avistaram o conduzido que se mostrou surpreso com a presença da equipe. De imediato, o conduzido declarou: "perdi senhor". Em revista pessoal, ao ser abordado, com o indivíduo foram encontradas as drogas apreendidas - porções fracionadas e acondicionadas para o varejo de substância análoga a maconha - e a quantia de R\$ 104,00 (cento e quatro reais). O conduzido confessou que estava traficando no local e que possui diversas passagens criminais. Após os fatos, a ocorrência foi apresentada nesta unidade de polícia judiciária". No mesmo sentido foram as declarações do policial militar, e testemunha, Marcos Mateus Ribeiro, ouvido apenas em solo policial à fl. 05.

O policial militar Ailton, em juízo, disse, inicialmente, que se recordava apenas da fisionomia do acusado. Questionado pelo promotor de justiça, disse se recordar dos fatos, informando que estava em patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de venda de drogas, quando se depararam com o acusado saindo de trás de uma placa de alumínio, encostado entre um muro e uma casa. Narra que, sabendo do movimento constante do tráfico de drogas, o abordaram e, em revista pessoal, encontrou drogas em poder do acusado. O réu confessou o crime no local dos fatos. Informou que ele possuía cocaína, maconha e crack em seu poder, além de pouca quantia em dinheiro.

Portanto, a pretensão punitiva estatal é procedente.

A análise dos autos revela que não há motivos para não se atribuir credibilidade ao depoimento do agente público ouvido no presente feito, haja vista que ele é coerente e harmônico entre as demais provas, bem como porque não se demonstrou que ele poderia ter qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa ao acusado ou, inclusive, forjado uma situação incriminatória ao réu. O simples fato de tal testemunha ser policial não a torna desmerecedora de confiança, de forma que caberia ao réu a comprovação de razões ponderáveis para tanto, o que não ocorreu no caso em tela. Ademais, o acusado confessou a prática delitiva.

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, firmado em tese, afirma que “é válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa ou responsáveis por prisão em flagrante, quando estiver em harmonia com as demais provas dos autos e for colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”. (Jurisprudência em Teses do STJ EDIÇÃO N. 105: PROVAS NO PROCESSO PENAL – I)

Ademais, a jurisprudência tem admitido que, por se tratar de atos emanados de agentes da Administração Pública, os depoimentos prestados por agentes públicos, sejam policiais civis ou militares, agentes de segurança penitenciária ou guardas municipais, possuem presunção juris tantum de veracidade e legitimidade, afastável somente mediante inequívoca demonstração em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso.

A propósito:

“Convém lembrar que os atos administrativos são dotados da presunção de veracidade e legalidade e, não havendo qualquer indício que possa macular esta qualidade, não é de se admitir, por simples contrariedade do sentenciado, que os depoimentos dos agentes públicos estejam eivados de ilegalidade, por um espírito emulativo ou qualquer outra causa espúria. Saliente-se que os depoimentos dos policiais valem como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, 'A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita' (STF, RTJ 68/54).” (Apelação nº 0004050-23.2013.8.26.0161 – 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo – Relator Willian Campos – julgado em 27 de maio de 2014 – votação unânime, grifei).

Não há dúvidas, ainda, que acerca da destinação dos entorpecentes encontrados com ele no momento de sua abordagem, quais sejam, 28,81g de tetrahydrocannabinol, droga popularmente conhecida como “maconha”, acondicionada em 47 porções, haja vista as circunstâncias da prisão, aliadas à natureza, diversidade e à quantidade de drogas que foram com ele apreendidas, comprovam, de maneira inequívoca, a finalidade mercantil. Como se não bastasse, o fato de ter sido apreendido o valor de R\$ 104,00 (cento e quatro reais) em dinheiro, que, ao serem considerados em conjunto com as circunstâncias já delineadas, demonstra, de maneira inequívoca, que tal valor era

proveniente da mercancia ilícita de drogas.

Consigne-se que, para a caracterização da traficância, a jurisprudência é remansosa acerca da desnecessidade de identificação de qualquer suposto cliente para o qual a droga se destinaria, também não sendo necessário que os agentes sejam observados ou abordados enquanto praticassem atos efetivos de mercancia.

Neste interim, está sedimentado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, sendo curial destacar que, o tipo penal descrito no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla e de natureza permanente, razão pela qual a prática criminosa se consuma, por exemplo, a depender do caso concreto, nas condutas de "ter em depósito", "guardar", "transportar" e "trazer consigo", antes mesmo da atuação provocadora da polícia, o que, no caso dos autos, remanesce o flagrante crime de tráfico de drogas.

O acréscimo punitivo da agravante prevista no artigo 61, inciso I, alínea "j" do Código Penal, como requer o Ministério Público, no caso concreto, é injustificável, na medida em que não relacionado com o maior desvalor da conduta. Não há nos autos prova no sentido de que o réu tenha efetivamente se valido das fragilidades ocasionadas pela pandemia para delinquir, sob pena de responsabilização objetiva. Portanto, inexistente qualquer relação entre a prática delitiva e os efeitos da calamidade pública, despropositada sua aplicação.

Por estarem comprovadas, portanto, autoria e materialidade delitivas, bem como o fato de que as substâncias entorpecentes apreendidas em sua posse tinham destinação mercantil, a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas é medida de rigor.

Passo à aplicação da pena.

A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando ligada tanto às particularidades fáticas do caso concreto quanto às especificidades subjetivas dos agentes. No crime de tráfico de drogas, a expressa dicção legal do artigo 42 da lei 11.343/2006 determina ao juiz, quando da fixação das penas, considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, que podem permitir o aumento da pena-base do condenado.

Atendendo às disposições constantes do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, bem como ao critério trifásico previsto no artigo 68, do Código Penal, verifico que o acusado ostenta duas sentenças condenatórias transitadas em julgado (certidão de fls. 98/100), sendo que uma será relevada como reincidência, na fase própria da dosimetria da pena, e a outra relevada como Maus Antecedentes do acusado. A quantidade das drogas apreendidas em seu poder, por seu turno, não habilita a majoração da pena-base. Assim, ante seus Maus Antecedentes, majoro a pena-base acima do mínimo legal, e fixo-a em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, este juízo entende que a agravante da reincidência deve ser minorada em face do reconhecimento da atenuante referente à confissão espontânea, de modo que agravo a pena em 1/12 avos, atingindo o patamar de 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 07 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO E 677 (SEISCENTOS E SETENTA E SETE) DIAS-MULTA. Cumpre consignar que este juízo não entende ser possível a compensação da agravante da reincidência pela atenuante da confissão espontânea, tendo-se em vista que a reincidência é circunstância preponderante à confissão espontânea, com fulcro no artigo 67, do Código Penal. Por oportuno, que o acusado não faz jus à diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, por ser reincidente.

O réu iniciará o cumprimento de sua pena no regime FECHADO, em obediência aos parâmetros contidos no artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal e no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90, uma vez que, embora a pena fixada não seja superior a oito anos, tal regime é o único recomendável ao caso dos autos, ante a elevada culpabilidade de agentes que cometem tráfico ilícito de entorpecentes, e se encontra em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (artigo 5º, inciso XLIII), não se podendo olvidar, aliás, que o acusado é reincidente.

Ainda, atendendo a nova redação do art. 387, § 2º, CPP, dada pela lei 12.736/12, mantenho o regime FECHADO, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, uma vez somente ao juiz da execução penal compete avaliar se, na espécie, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de qualquer benefício com a observância do acompanhamento disciplinar até o final do cumprimento da pena. Não se pode, dessa maneira, vincular à progressão de regime um mero procedimento de cálculo aritmético de cumprimento de pena, ignorando o mérito do sentenciado e, verdadeiramente, negando vigência ao que estabelece o art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se encontra revogado. Ademais, ainda que assim não fosse, observo que, embora se possa saber o tempo que o réu permaneceu custodiado, não dispõe esta Magistrada de informações seguras sobre a satisfação dos demais requisitos para a detração da pena ou eventual progressão de regime, o que reforça a tese de que a avaliação dos requisitos indispensáveis à concessão desses benefícios somente é possível pelo Juízo da Execução da pena, nada se podendo fazer neste momento do processo.

O valor de cada dia-multa será o mínimo legal, isto é, um trigésimo do salário mínimo vigente no dia do fato, corrigido em sede e executado em sede de execução, nos termos do artigo 49, parágrafo 2º e 51, ambos do Código Penal, por não haver provas nos autos de que o réu possua boa situação financeira.

É incabível o sursis, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, ante a reincidência do réu.

Do exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA, para o fim de CONDENAR o acusado DIEGO THOMAZ FERREIRA, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 07 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO, no regime inicial FECHADO, vedadas quaisquer substituições previstas em Lei, bem como à pena de 677 (SEISCENTOS E SETENTA E SETE) DIAS-MULTA, pelo cometimento do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 61, inciso I, e com o artigo 65, inciso III, "d", ambos do Código Penal.

O réu permaneceu preso durante todo o trâmite processual, o que demonstra que subsistem os requisitos da prisão preventiva, máxime agora, com sentença penal condenatória, não havendo, pois, quaisquer motivos para a concessão de liberdade provisória em seu favor, pelo que não poderá apelar em liberdade.

Nesse sentido:

"É pacífico na jurisprudência que o direito de recorrer da sentença penal condenatória em liberdade não se aplica ao réu já preso em decorrência de flagrante ou de prisão preventiva, que assim permaneceu durante todo o curso da instrução criminal, ou pelo menos grande parte dele.

Confira-se, a respeito, o posicionamento desta C. Câmara, ao decidir questões semelhantes:

'Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória. Pedido de apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Paciente permaneceu sob custódia do Estado durante a instrução processual. Ordem denegada.' (HC nº 0276546-35.2011.8.26.0000, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j. 16/02/2012, V.U.).

'HABEAS CORPUS - Tráfico de Entorpecentes - Regime inicial fechado - Fixado de acordo com a legislação vigente - Apelo em liberdade vedado - Réu que permaneceu preso durante o processo - Não ofensa à garantia constitucional da presunção de inocência - Ordem denegada.' (HC nº 0181659-59.2011.8.26.0000, Rel. Des. Miguel Marques e Silva, j. 12/04/2012, V.U.).

O C. Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou a respeito, afirmando: 'A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal.' (RHC nº23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008).

Deveras, não haveria qualquer lógica em manter o acusado preso durante a instrução e, sobrevindo condenação, ainda que não transitada em julgado, soltá-lo para aguardar o julgamento da apelação interposta. Ao contrário, a prolação de sentença condenatória reforça e ratifica o cabimento da prisão. Assim, não se caracteriza, aqui, medida desproporcional que revele o alegado constrangimento do paciente." (Habeas Corpus nº 2055783-89.2013.8.26.0000 - 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo - Relator De Paula Santos - julgado em 27 de março de 2014 - votação unânime).

Recomende-se o réu no local em que se encontra preso, comunicando-se a alteração da natureza de sua custódia.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que nesta oportunidade lhe concedo os benefícios da gratuidade da justiça, em razão de ter sido defendido pela Defensoria Pública no presente feito.

Por se tratar de proventos auferidos com a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, determino o perdimento dos valores apreendidos nos presentes autos, nos termos do artigo 63 e respectivos parágrafos da Lei nº 11.343/06. Oficie-se à autoridade policial para a destinação cabível, nos termos do artigo 516, das NSCGJ.

Providencie-se a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas (artigo 32 e respectivos parágrafos da Lei nº 11.343/06).

P.I.C.

Franco da Rocha, 14 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA